

PETIÇÃO INICIAL EM ANEXO



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA
PÚBLICA MUNICIPAL DE GUARAPARI – COMARCA DA CAPITAL**

ABREU JÚDICE PARTICIPAÇÕES LTDA, Sociedade Empresária Limitada (Cod. 206-2), inscrita no Cadastro de Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 34.727.838/0001-01, estabelecida na Rua Judith Maria Tovar Varejão, nº 373, sala 1-F, CEP nº 29.050-360 Enseada do Suá, neste ato, representada pelo seu sócio-administrador sr. **Fernando de Abreu Júdice**, brasileiro, casado, advogado, residente na avenida Desembargador Santos Neves, nº 731, complemento 1002, Ed. Itamaraty, Praia do Canto, CEP nº 20.055-723 (**Doc. 02 e 03**), vem, respeitosamente, por seus advogados infra-assinados, devidamente qualificados no instrumento de mandato em anexo (**Doc.01**), **impetrar** a presente ação de

MANDADO DE SEGURANÇA

em face de ato inconstitucional, abusivo e ilegal praticado pelo
Sr. Secretário de Fazenda do Município de Guarapari, que, conforme de depreende dos atos praticados e constantes do Procedimento Administrativo nº18.384/2020 I (**Doc. 04**), acolheu o Parecer subscrito pela DD Procurador do Município, Dr. Arthur Daher Colodetti, determinou o encaminhamento do processo administrativo à Supervisão de Tributos, a fim de emitir guia de recolhimento da exação do ITBI, cuja garantia de imunidade encontra-se constitucionalmente garantida, como se confluirá ao longo das argumentações fáticas e de direito a seguir:

Rua Judith Maria Tovar Varejão, 373, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abreujudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477



À fls. 49, como demonstrado pela figura a seguir, consta a observação escrita que em **28.04.2021** fora encaminhado ao representante legal da Impetrante e-mail com a cópia apenas do Parecer da Procuradoria Municipal e da guia para recolhimento do tributo. Na ocasião, não foi anexado ao e-mail qualquer decisão formal, subscrita pela Autoridade Impetrada.

Adquirente : 349320 ABREU JUDICE PARTICIPAÇÕES LTDA		CPF/CNPJ : 34.727.838/0001-01	
Anuente :		CPF/CNPJ :	
Usufrutuário :		CPF/CNPJ :	
Dados do Imóvel : 82.83.896.8345.887.29288888 - VINA DEL MAR, 298 ED PRAZA DE SACUTIA APT0 201 - Bairro: NOVA GUARAPARI - Q/L: 15/18/13			
Natureza Operação:			
Observações: AVALIADO EM R\$ 1.100.000,00 INTEGRALIZADO O VALOR DE R\$ 220.000,00 VAL OR EXCEDENTE COBRADO R\$ 880.000,00			
Valor Avaliado:	880.000,00	Protocolo:	18384
Valor Aquisição:	220.000,00	Ano Protocolo:	2020
Qtde Jsofruto:	0	Fração Ideal:	1,000000
Qtde Anuência:	0	Tp Averbação:	Residencial
Base Laudêmio:	0	Qt Averbação:	1
Percentual Consid:	100,00%		
IdGuia :	5403190	IdParcela :	16082763
Via Banco		RECEITA	
		17 - Averbação	
		35 - ITBI	
		VALOR	Vencimento
		90,11	28/05/2021
		17.690,00	
		Valor em R\$	17.690,11
		Nro Parcela	1
81700000176-5 90111765202-3 10528019001-5 60827630000-1			
			

Não receber após o vencimento.

Enviado por email em
28/04/2021

Por sua vez, consta na reprodução acima que a cópia do respectivo procedimento administrativo (**Doc. 04, fl. 48**) somente fora encaminhado ao representante da Impetrante em **30.06.2021**, conforme corrente de e-mails em anexo (**Doc. 06**). Por sua vez, a exigência tributária tinha como **dies ad quem 28.05.2021**.

Tomando por base quaisquer das datas apontadas, desde a mais conservadora (28.04.2021), até a mais próximas (30.06.2021), conclui-se que a impetração se dá dentro do prazo legal e decadencial de 120 (cento e vinte) dias da ciência, previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009¹.

O Ato Coator, por conseguinte, está na conduta do Sr. Secretário de Fazenda que, em observância ao conteúdo do Parecer subscrito pelo Douto Procurador Municipal, Dr. Arthur Daher Colodetti, determinou que o procedimento administrativo seguisse à Supervisão de Tributos para que se fizesse, como de fato se fez, a exigência tributária, sendo certo que a ciência por parte do representante do impetrante se deu em 28/04/2021.

¹ Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



Portanto, a impetração do presente Mandado de Segurança encontra-se dentro do prazo decadencial.

II. DA LEGITIMIDADE E DO INTERESSE JURÍDICO DA IMPETRANTE:

O parágrafo 5º da Cláusula 4ª do Contrato Social (**Doc. 02**), ao tratar do capital social e sua integralização, prevê ser ônus e obrigação da Impetrante, então constituída, arcar com todas as despesas e fazer o aporte dos valores necessários à transferência da propriedade imobiliária, pelo que manifesta é a legitimidade e indiscutível o interesse jurídico para o manejo do presente Mandado de Segurança. A conferir:

Parágrafo Quinto: Caberá a Sociedade que recebe os bens arcar e suportar de forma isolada com as despesas de transferência dos referidos imóveis à sociedade, como também com as despesas para obtenção das baixas dos gravames e/ou aceite dos terceiros quanto a presente transferência por incorporação de capital social e, ainda, toda e qualquer despesa necessária para a regularização de limites e confrontações, como também obras e benfeitorias existentes.

III. DA QUESTIO IURIS SUSCITADA NESTA SEDE MANDAMENTAL:

A *questio iuris* a ser decidida por Vossa Excelência emerge de uma equivocada interpretação conferida pela Autoridade Impetrada **ao inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal e, na sequência, aos arts. 36, I e II e 37 do Código Tributário Nacional.**

Esse equívoco manifesto viu-se expressado no respeitável Parecer do Procurador Municipal Arthur Daher Colodetti, ao final, acolhido *in totum* por ato da Autoridade Impetrada afastando, para o caso, o reconhecimento da imunidade total do ITBI em razão de integralização de imóvel, situado no município de Guarapari/ES, na constituição do capital societário da Impetrante.

O ato da Autoridade Impetrada, ao encampar a integralidade dos fundamentos do Parecer de sua Douta Procuradoria, reconhece, somente em parte, a imunidade, até o valor de integralização do imóvel, pelo que, havendo por parte do Município de Guarapari avaliação maior (valor venal), entendeu-se pela incidência do imposto sobre o

Rua Judith Maria Tovar Varejão, 373, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abrejudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477



valor da diferença a ser apurada, como de fato o foi, gerando, inclusive, a guia (**Doc. 05**) para recolhimento do tributo no valor de R\$ 17.690,11 (dezesete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos), em 28.05.2021.

O imóvel a que se refere a (não-)incidência tributária cuida-se do apartamento nº 201, do Edifício Praia de Bacutia, situado na avenida Viña del Mar, na Enseada Azul, em Nova Guarapari, neste município, que foi adquirido e constava da Declaração de Imposto de Renda (**Doc. 08 e 09**) dos seus então proprietários, casados em comunhão universal de bens, Fernando de Abreu Júdice e Ana Rita Marques Júdice, pelo valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). O item "f" do parágrafo segundo, da Cláusula 4ª, do Contrato Social, que cuida pormenorizadamente do "CAPITAL SOCIAL E SUA INTEGRALIZAÇÃO", assim dispõe:

f) 01(um) apartamento residencial de n.º 201, com 2(duas) vagas de garagem, Edifício Praia de Bacutia, situado na Avenida Viña Del Mar, nº 298, Guarapari (ES), CEP. 29206-170, adquirido(a) na data de 29/06/2006, por meio de escritura publica de compra e venda lavrada no livro 139S2, as folhas 207/209 do Cartório Sarlo, Imóvel registrado no **Cartório de Registro de Guarapari/ES- 2º Ofício**, sob Matrícula nº 43.799, livro 2, pelo valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), já atualizado na declaração de imposto de renda, sendo este valor considerado para fins desta incorporação;

Vale enfatizar que este valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) constantes da declaração de bens do sócio Fernando Júdice prestada à Receita Federal do Brasil não comportou atualização no momento da integralização nos exatos limites previstos e permitidos em lei, por opção do contribuinte, a fim de não ficar sujeito ao imposto de renda sobre o ganho de capital. Esse foi o custo de aquisição para a pessoa jurídica e, na declaração de bens da pessoa física que o integralizou, o espaço destinado ao imóvel foi composto pelas quotas subscritas na mesma proporção (220 mil quotas referentes ao imóvel integralizado - Doc. 06). Esta opção é legítima e prevista expressamente no art. 23 e parágrafos da Lei nº 9.249/1995:

Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, **a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.**

§ 1º **Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos,** não se

Rua Judith Maria Tovar Varejão, 373, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abreujudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477



aplicando o disposto no [art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977](#), e no [art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983](#).

§ 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital.

Preferiu o sócio Fernando de Abreu Júdice, por oportunidade da integralização, manter o valor do imóvel constante da sua respectiva declaração de bens, nos limites da lei, para efeito de não se submeter à incidência de imposto federal (IR sobre o ganho de capital). Houvesse atualização voluntária, incidiria, no máximo, sobre essa legítima operação, o imposto federal sobre eventual ganho de capital, mas jamais, uma vez integralizado o imóvel como realização de capital, o imposto municipal (ITBI) devido a regra constitucional imunizante.

Uma vez integralizado o imóvel², nos termos do quanto permitido pelo art. 23 da Lei nº 9.249/1995, impera a imunidade do ITBI prevista no texto constitucional, como será demonstrado amiúde.

Vale enfatizar, ainda: a opção legítima do sócio-contribuinte ao integralizar imóvel seu como realização de capital social de uma empresa da qual fará parte, sem atualizá-lo a valor presente de mercado, não pode ensejar a incidência de ITBI pela diferença a maior entre o valor integralizado e o valor venal proposto pelo município. Esse não é o comando constitucional específico e, tampouco, o que restou decidido pelo STF por ocasião do julgamento do Tema 796.

Essa situação pretendida pela municipalidade, **por ato abusivo e ilegal da Autoridade Impetrada**, traz consequências fiscais, posto instituir assimetria com a legislação de regência, na medida em que se terá atualização do valor do imóvel, para efeito de incidência de ITBI sobre a diferença em relação ao valor de aquisição, ao passo que não se terá, para efeitos fiscais, atualização do valor do capital social, e, tampouco, reserva de capital em aumento do patrimônio. Tudo conforme autoriza a legislação federal que faculta ao contribuinte não o fazer para não se submeter, de imediato, ao Imposto de Renda sobre o

² Cumpriram os sócios Fernando e Ana Rita o disposto no Código Civil Brasileiro em face do qual respondem por cinco anos:

Art. 1.055. O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio.

§ 1º Pela exata estimação de bens conferidos ao capital social respondem solidariamente todos os sócios, até o prazo de cinco anos da data do registro da sociedade.



ganho de capital (imposto federal), diferindo-o para o futuro, por ocasião de eventual alienação das cotas; todavia, contraditoriamente, o contribuinte vê-se obrigado a atualizar o valor do imóvel para efeito de se submeter a um imposto municipal indevido, na contramão de clarividente imunidade constitucional.

Enquanto a lei federal confere um benefício com uma mão: a mão da lei federal; de outro lado, o município pretende retirá-lo com outra mão: com a mão da ilegalidade, mediante indevidas e equivocadas leitura e interpretação constitucionais.

IV. DA IMUNIDADE CONSTITUCIONAL PREVISTA NO § 2º DO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DA ADEQUADA SUBMISSÃO DOS ARTS. 36 E 37 DO CTN AO PRECEITO CONSTITUCIONAL DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA:

A matéria sub judice tem índole diretamente constitucional. A propósito, eis a dicção dos preceitos constitucionais que regem a tema:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - **não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital**, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, **nesses casos**, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

O inciso II do art. 156 da Constituição Federal de 1988, em sua redação, prevê ser da competência dos Municípios a instituição de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) inter vivos, bem como de direitos reais sobre imóveis e cessão de direitos a sua aquisição.

Entretanto, o dispositivo constitucional, em seu § 2º, inciso I, traz uma regra imunizante ao afirmar que o ITBI "não incide sobre a transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital". Observe-se que,

Rua Judith Maria Tovar Varejão, 373, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abrejudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477



nesse preceito, condizente com a primeira hipótese de imunidade, não há qualquer ressalva ou exceção estabelecida pelo texto constitucional.

É o que ocorre no caso sub judice com a integralização do imóvel pertencente ao sócio da Impetrante, Fernando de Abreu Júdice. O imóvel foi integralizado pelo valor constante da declaração de bens (R\$ 220.000,00) e transformados em quotas proporcionais, ou seja, em 220 mil quotas referente ao respectivo imóvel.

O imóvel em epígrafe integraliza o capital social da impetrante pelo exato valor constante da declaração de bens dos sócios, correspondendo à mesma grandeza em termos de quotas subscritas, não havendo qualquer diferença a maior, ou a menor. Não houve, portanto, discrepância entre o patrimônio da sociedade e o seu capital, no pormenor; e, tampouco, ficou registrado parte do valor à conta de reserva de capital ou de ágio.

Por sua vez, a leitura da regra constitucional nos permite detectar imunidade tributária para duas situações, e uma exceção apenas para a segunda situação prevista:

- i - criação de empresa com a integralização pelos sócios de imóveis seus para a realização de capital e
- ii - sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica.

A única exceção para a aplicação da regra imunizante e, assim, permitir a incidência do tributo, reside na hipótese de a atividade preponderante da empresa adquirente, nos casos de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, "for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil". E essa exceção à regra imunizante aplica-se somente à segunda parte do texto, nos casos de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, o que, também, não é a hipótese com a qual se depara a impetrante.

Com isso, pode-se afirmar, adiantando-se ao que será detalhadamente exposto, não ter sido recepcionado o art. 37 do Código Tributário Nacional para a

Rua Judith Maria Tovar Varejão, 373, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abreujudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477



hipótese primeira constante da parte inicial da locução normativa: "não incide sobre a transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital".

O art. 37 do CTN só tem, atualmente, aplicação para as hipóteses previstas na segunda locução da regra constitucional, que corresponde ao inciso II, do art. 36, e, assim, a imunidade deixará de existir³. Observemos a locução do texto constitucional: "nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil".

Essa moldura interpretativa ficou adequadamente assentada pelo Supremo Tribunal Federal por oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, Tema 796, em regime de Repercussão Geral, quando a maioria de seus membros acompanhou o voto vencedor do ministro Alexandre de Moraes, pelo que, desde já, afirma-se que a ilustre Procuradoria do Município de Guarapari fez uma inadequada leitura dos votos proferidos, bem como da tese estabelecida e, principalmente, da *ratio decidendi* do julgamento.

É o que se demonstrará a seguir, nos tópicos 5 e 6.

³ Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;

II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

§ 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.



V. DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO 796.376/SC, TEMA 796 – REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL

O *thema decidendum* já se encontra definido no âmbito do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE nº 796.376/SC, Tema 796, em regime de repercussão geral, , independentemente das críticas doutrinárias que possam ser lançadas quanto à conclusão a que se chegou.

Embora não se possa atribuir uma eficácia *erga omnes*, direta e imediata, ao acórdão/precedente oriundo de Recurso Extraordinário julgado pelo STF, em regime de repercussão geral, porquanto tanto o § 3º do art. 102, da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, quanto o rol do art. 927, CPC/2015 não a preveem, pode-se afirmar que, atualmente, os temas julgados sob o acicarte da repercussão geral estão imersos em uma teia de vinculações jurídicas dentro do âmbito do Poder Judiciário, a partir do que se pode inferir do sistema recursal disciplinado pela nova Codificação Processual em vigor.

Vejamos o art. 1.030 e seus incisos, do CPC/2015: quanto aos temas constitucionais, cuja a repercussão geral não tenha sido reconhecida, a lei processual determina que, nesses casos, deva se negado seguimento ao Recurso Extraordinário que se pretenda rediscutir a questão, prevalecendo o acórdão recorrido, bem como não deve ser conhecido o recurso contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF (inciso I). Já o inciso II, estabelece que a causa deverá ser reexaminada pelo tribunal *a quo*, em juízo de retratação, na hipótese de o acórdão recorrido divergir do entendimento estabelecido pelo STF no regime da repercussão geral⁴.

⁴ Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [\(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016\) \(Vigência\)](#)

I – negar seguimento: [\(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016\) \(Vigência\)](#)

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; [\(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016\) \(Vigência\)](#)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; [\(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016\) \(Vigência\)](#)

Rua Judith Maria Tovar Varejão, 373, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abreujudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477



O § 5º do art. 1.035 do atual Código de Processo Civil determina que, uma vez reconhecida a existência de repercussão geral, todos os demais processos que tratam de igual matéria haverão de ter seu curso e julgamento sobrestados. Por sua vez, o § 8º dispõe: *§ 8º "negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica"*, o que evidencia a vinculação, mantendo-se o acórdão recorrido⁵.

Logo, extrai-se uma vinculação jurídico-recursal quanto ao resultado do julgamento da matéria sob o regime da repercussão geral, evitando-se, por cautela, decisões conflitantes com a da Corte Suprema.

Portanto, esse reflexo inexorável cuida-se de uma forma de vinculação jurídica dos recursos, sobrestados e futuros, ao resultado do que vier a ser decidido no âmbito do Recurso Extraordinário, a teor do disposto na segunda parte da alínea *a* do inciso I, do art. 1.030, do novo Diploma Processual.

⁵ Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

§ 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.

§ 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.

§ 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:

I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;

II - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.

§ 4º O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

§ 6º O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.

§ 7º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 8º Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.



A matéria julgada sob o regime da repercussão geral tem alto valor jurídico, tanto que o parágrafo único do art. 988, CPC/2015⁶, assegura seu exame independentemente de haver desistência recursal, a fim de que a tese seja fixada.

Toda essa análise demonstra, à saciedade, que em face do Tema 796, já decidido pelo Supremo Tribunal Federal sob o regime da repercussão geral, os resultados dos julgamentos vindouros haverão de estar alinhados, como sói ocorrer no caso *sub judice*.

No tópico abaixo será inteiramente dissecado o acórdão do STF, fruto do Tema 796, a fim de esclarecer o alcance da tese fixada e, principalmente, a *ratio decidendi* do precedente, **evidenciando-se a liquidez e certeza do direito da impetrante à imunidade total do ITBI quanto à integralização do respectivo imóvel como parte do capital na constituição da pessoa jurídica.**

VI. DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO DA IMPETRANTE – DA SUA RATIO DECIDENDI E DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO 796.376/SC – TEMA 796 – UMA RELEITURA DO TEXTO CONSTITUCIONAL FEITA PELO STF – INDIRETA VINCULAÇÃO DE TODOS OS JUÍZOS PELOS EFEITOS DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL:

Nesse tópico serão metodicamente descortinadas a tese e a *ratio decidendi* fixadas pelo STF quanto à matéria *sub judice*, possibilitando a Vossa Excelência concluir pela incontestável existência do direito líquido e certo deduzido: a impetrante faz jus à imunidade (não-incidência) total do ITBI quanto à integralização do respectivo imóvel pelo valor constante da declaração de bens e direitos do seu sócio, como parte do capital na constituição da pessoa jurídica.

Antes de avançarmos para o exame da tese fixada e da sua *ratio decidendi*, urge seja observado o tema então debatido por ocasião do acolhimento da repercussão geral, a fim de que o cotejo com o que posteriormente foi fixado possibilite a

⁶ Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquele objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.



adequada compreensão, sobretudo, da *ratio decidendi* compondo-se, com precisão, o alcance da base espacial da tese estabelecida:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, IV, 5º, II e XXXVI, 37, caput, 156, § 2º, I, e 170 da Constituição Federal, o alcance da imunidade tributária do Imposto de Transmissão *Inter Vivos* de Bens Imóveis - ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da Lei Maior, em relação à incorporação de imóveis ao patrimônio de empresa, nos casos em que o valor total desses bens excederem o limite do capital social a ser integralizado.”

Veja-se, pois, que se discutiu o alcance da imunidade tributária do ITBI na hipótese de incorporação de bens imóveis ao patrimônio da empresa, todavia, **no caso do citado precedente, grande parte do valor dos imóveis ficou reservada à conta de reserva de capital ou de ágio, vale dizer, o valor desses bens excederam o capital social integralizado.**

À luz dessa moldura fática fixou-se, em sede de repercussão geral a tese por ocasião do Tema 796, com a seguinte dicção: *"a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"*.

Veja que nesta tese o valor do capital integralizado era inferior ao valor dos imóveis, entretanto, reservou-se parte, ou grande parte desse valor, à conta de reserva de capital ou de ágio.

Esse **não-alcançar o valor dos bens que, porventura, exceder o limite do capital social a ser integralizado**, para efeito de afastar a imunidade tributária, **refere-se**, à luz do quadro fático da hipótese decidida em regime de repercussão geral pelo STF, **à circunstância na qual reservaram os sócios parte, ou grande parte, do valor dos imóveis integralizados à conta de reserva de capital ou de ágio, não se assemelhando, portanto, à situação *sub judice* em que se integraliza imóvel pelo integral valor constante da declaração de bens e direitos do seu respectivo sócio (R\$ 220.000,00) e transformando-o em quotas proporcionais, ou seja, em 220 mil quotas referente ao respectivo imóvel.**

No presente caso, ora sob julgamento, optou-se, à luz da faculdade legal (art. 23 da Lei no 9.249), por não atualizar o preço do imóvel ao valor de mercado. Nessa

Rua Judith Maria Tovar Varejão, 373, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abrejudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477



hipótese não há qualquer possibilidade de a municipalidade pretender atualizar, compulsoriamente, o valor do bem imóvel, a fim de justificar a incidência do ITBI sobre essa diferença de valores.

Cotejando o tema com a tese fixada observa-se que, quanto a esta última, o seu adequado alcance e sua adequada compreensão, para efeito de não se reconhecer a imunidade constitucional tributária, refere-se à hipótese em que o valor do bem integralizado excede, por voluntariedade dos sócios, o capital social estipulado como integralizado, fazendo com que *a diferença seja lançada, à conta de reserva de capital ou de ágio, no patrimônio líquido*.

Não obstante, e desde já se adianta, a devida compreensão da tese requer uma leitura atenta do voto vencedor e uma específica atenção para o quanto discutido nos autos, principalmente atenção à moldura fática da qual emergiu a tese.

Como já ressaltado, o julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, Tema 796, envolvia uma particularidade específica, com a qual a realidade da impetrante não comunga.

Vejamos a diferença: o caso a que se refere o precedente teve início com mandado de segurança impetrado por *holding* de participações de Santa Catarina contra ato do Secretário da Fazenda do município de São João Batista (SC). O contribuinte invocara a imunidade do ITBI para integralizações de capital, prevista no artigo 156, §2º, I, da Constituição.

A Fazenda municipal negou a imunidade ao Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre o valor total dos bens. A justificativa: o valor dos imóveis excedia o capital efetivamente integralizado. Assim, reconheceu-se a imunidade apenas com relação à parcela ao capital social da sociedade.

Como denotam os autos daquele processo, *"o capital social da recorrente foi integralizado mediante incorporação de imóveis com valor superior ao das cotas subscritas, sendo a diferença lançada, à conta de ágio, no patrimônio líquido". Ou seja, do valor atribuído aos bens na integralização, parte foi destinada ao aumento do capital social e*



parte à conta de reserva de ágio, aumentando o patrimônio da sociedade, mas não seu capital⁷. Dessa particularidade, repita-se, não comunga o caso ora *sub judice*.

O que o município não aceitou, portanto, foi a imunidade sobre a parcela atribuída à reserva de ágio, reconhecendo, todavia, a não-incidência do ITBI sobre a parcela do valor dos bens que efetivamente integralizara o capital da sociedade.

No presente caso, a Autoridade Impetrada pretende tributar uma diferença de valores não em virtude da integralização em si, que se deu conforme faculta o art. 23 e parágrafos da Lei nº 9.249/95 (pelo valor constante da declaração de bens do sócio), *mas em razão de uma fúria arrecadadora que visa criar um factoide ilegítimo, ou seja, uma situação patrimonial que está fora do campo da incidência tributária, ao pretender fazer prevalecer o valor venal encontrado pela municipalidade e, sobre a diferença desse valor em relação ao valor integralizado, lançar o ITBI.*

Por sua vez, é legítimo aos sócios preferir não atualizar o valor do imóvel ao preço de mercado antes da integralização do mesmo ao capital social de pessoa jurídica. Essa opção não dá ensejo a que o Município o faça para cobrar o ITBI sobre a referida diferença de valores.

Importante destacar que houvesse sido atualizado o bem imóvel ao preço de mercado, para efeito da integralização, o imposto a incidir seria o IR sobre o ganho de capital, mas jamais o ITBI.

A diferença de bases factuais entre o caso *sub judice*, quando contrastado com aquele condizente ao julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, Tema 796, em regime de Repercussão Geral, é de todo relevante.

Para a melhor compreensão do quanto decidido pelo STF necessário se analisar a *ratio decidendi* do precedente do Supremo Tribunal Federal.

⁷ Essa possibilidade é prevista pela Lei 6.404/76, a Lei das S.A.:

"Artigo 182 - A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.
§1º Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem: a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em ações de debêntures ou partes beneficiárias;"



A dita análise do voto vencedor nos indica que se estabeleceu distinção entre os significados de "*incorporação de bens em realização de capital*" e "*incorporação de bens ao patrimônio*", expressões que merecem distinção em virtude do que se disciplinou na primeira e na segunda orações do mesmo artigo 156, §2º, I, da CF ⁸.

Entendeu a maioria dos ministros da Corte Suprema que a primeira expressão se refere a integralizações de capital em sentido estrito; enquanto a segunda diz respeito às operações de fusão, cisão e incorporação, em que há transferência de patrimônio imobiliário de uma sociedade para outra, mas não resultando em aumento de capital social.

Com base nessa distinção, afirmou-se que a hipótese de imunidade ao ITBI na qual os bens imóveis não acrescem ao patrimônio seria apenas aquela citada no segundo trecho do referido dispositivo constitucional, consistente na fusão, cisão e incorporação. E que tais situações não se confundem com a imunidade para "*incorporação de bens em realização de capital*", em que, para fruição da imunidade, obrigatoriamente deve ocorrer integralização ao capital social. **Ou seja, a imunidade, nessa hipótese específica, não pode alcançar a parcela do valor dos bens que não acresce ao capital, posto que isso revelaria interpretação extensiva, que não seria admitido por nosso ordenamento.**

Assim, a *primeira conclusão* é de que: no caso de integralizações de capital, a diferença entre o valor dos bens imóveis que aumenta o capital social e a parcela do valor dos bens imóveis que é destinada à conta de reserva de capital ou de ágio, se essa for a vontade dos sócios, não é imune ao ITBI, devendo ser pago o imposto sobre a diferença.

⁸ C.f. A propósito, vale a leitura do trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE nº 796.376/SC:

“É dizer, a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2º, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I.

Nesses últimos casos, há, da mesma forma, incorporação de bens, mas que decorre da “incorporação que é uma operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações” (art. 227 da Lei 6.404/1976 – Lei de Sociedades Anônimas); cisão - operação pela qual uma sociedade transfere parte de seu patrimônio para uma ou mais empresas (art. 229 da Lei das S.A.); ou fusão - operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova sociedade que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações (art. 228 da Lei das S.A.).

Em todas essas hipóteses, há incorporação do patrimônio imobiliário de uma sociedade para outra, mas sem qualquer relação com a incorporação (integração) referida na primeira parte do citado inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF, que alude à transferência de bens para integralização do capital.”



Assim, caso todo o patrimônio imobiliário seja integralizado na conta de capital social, não há incidência do ITBI.

Essa é a *ratio decidendi*. Portanto, não pode ser dissociada da tese fixada.

Em síntese, disse o STF: que a imunidade somente alcança a operação de transferência de bens imóveis, em nome dos sócios, para a pessoa jurídica em realização de capital, caso o valor de tais bens não supere o do capital social declarado. No julgamento do *leading case*, retratado pelo Tema 796, a importância que sobejou o capital social foi declarada como reserva de capital e, como tal, não estaria respaldada na regra imunizante, segundo o STF.

Não obstante a clareza da *ratio decidendi*, poder-se-á lançar dúvidas a partir da tese firmada quanto à referência a ser adotada como parâmetro para se estabelecer o que deve entender por “valor dos bens” que se pretenda integralizar.

De imediato podemos afirmar que a imunidade ilimitada foi afastada pelo STF. Portanto, os que a defendem devem se curvar, pois, embora as contas de reserva de capital compoñham o patrimônio da sociedade (Lei 6.404/76, artigo 178, §2º, inciso III), entendeu a Corte Maior que, mesmo assim, haverá incidência do ITBI sobre o valor da diferença entre as grandezas integralizadas ao capital e aquelas lançadas a conta de reserva de capital.

Cuidando-se, pois, de imunidade limitada atenção à lei federal de regência se impõe, pelo que o valor disposto na declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) do sócio servirá como parâmetro para se realizar o cotejo com o valor do capital social, tal como previsto e permitido pela dicção do artigo 23 da Lei 9.249/95⁹.

⁹ Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§ 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.

§ 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital.



Ademais, como já mencionado, o diferimento, concedido pela União aos contribuintes que não desejam recolher o ganho de capital no momento da integralização, não pode ser tolhido pelos municípios.

Com efeito, não se põe em dúvida a intenção do legislador constitucional, ao prever a norma imunizadora: a de fomentar a economia, estimulando-se a criação de novas empresas, além de promover a geração de emprego e renda.

Ficou bem assentado, pela prevalência do voto do Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, Tema 796, em regime de Repercussão Geral, que a imunidade deve ser interpretada de forma estrita, pelo que não alcança o valor do imóvel **não destinado** "à integralização do capital subscrito, e sim a outro objetivo — como, no caso presente, em que se destina o valor excedente à formação de reserva de capital". Portanto, a *ratio decidendi* do precedente revela que: **a imunidade deve se restringir ao que foi registrado em contrapartida de capital e, assim, a parcela do valor do imóvel registrada como "reserva de capital" deve ser tributada.**

A *contrario sensu*: **a imunidade deve ser absoluta quando, na integralização do capital da pessoa jurídica, o imóvel for vertido com todo o valor constante da declaração de bens dos sócios, e, assim, integralizado, sem reservas de valor à conta de reserva de capital ou de ágio.**

Objetivamente, podemos resumir que a situação analisada pelo STF envolve empresa que recebeu imóveis de seus sócios no contexto do aumento do seu capital social. No entanto, somente parte do valor do imóvel foi registrada em contrapartida do capital social. O restante foi destinado à conta de reserva de capital, que também compõe o patrimônio líquido de uma pessoa jurídica. Esse procedimento é bastante comum e inclusive determinado pela Lei das S.A., em seu artigo 13, parágrafo segundo.

Entretanto, a discussão no julgamento do RE nº 796.376/SC, Tema 796, em nada tem a ver com a incidência de ITBI sobre a diferença entre o valor de mercado do imóvel e seu valor de declaração, hipótese sem qualquer respaldo legal.

Não se discutiu, em momento algum, por ocasião do julgamento referido, eventual dissonância entre o valor integralizado e o valor de avaliação dos bens pelo município, o que sequer ocorreu no caso. Eis, nesse contexto,

Rua Judith Maria Tovar Varejão, 373, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abrejudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477



trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, o que evidencia bem a questão: *"os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica que não fossem destinados à integralização do capital subscrito, e sim a outro objetivo — como, no caso presente, em que se destina o valor excedente à formação de reserva de capital"*.

Entendeu-se, portanto, que a imunidade *"não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"*, sendo possível, portanto, a incidência do tributo na faixa entre o valor do capital social e o valor histórico dos bens integralizados. A expressão "exceder" refere-se aos valores constantes da integralização e não a outros valores, ad instar do valor venal, valor de mercado etc.

O precedente do STF, do qual se vale o ato coator para justificar a exação, não autoriza, sob hipótese alguma, a cobrança sobre suposta diferença entre o valor do capital social e o valor da avaliação unilateral (e, muitas vezes, arbitrária) por parte do município. Eis aí o *distinguishing*!

Qualquer pretensão nesse sentido, além de desrespeitar a *ratio decidendi* da decisão proferida pelo Supremo, viola a imunidade prevista no artigo 156, §2º, I, da Constituição Federal. Além disso, esse ato administrativo, fomentado pela gula arrecadatória, feriria o direito líquido e certo do contribuinte de integralizar os bens pelo valor histórico, como lhe faculta o artigo 23 da Lei 9.249/1995, sem incidência do ITBI.

Quando o *caput* do art. 23 da Lei nº 9.249/95 assegura que *"as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado"*, prevê direito de opção de o contribuinte não se submeter, de imediato, ao IR sobre ganho de capital e diferi-lo para o futuro, para eventual ocasião de venda das quotas ou ações pelos sócios. Por sua vez, o parágrafo 1º está a legitimar esse opção, ao estabelecer que *"se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos"*. Por outro lado, disciplina o parágrafo 2º: *"se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital"*. Nesse quadrante, onde está a legitimidade de os municípios exercerem sua competência tributária e a sua capacidade ativa tributária para efeito de se exigir o ITBI? Não há possibilidade para isso!



Não se afigura legítimo e constitucional o raciocínio jurídico desenvolvido pelo município de Guarapari/ES ao verificar que suposta parcela correspondente ao ganho de capital, que deixou de ser auferido e submetido ao IRPF, haverá de sofrer incidência tributária do ITBI, em atenção ao suposto princípio de que algum tributo há sempre de ser pago e à necessidade de preservação da finalidade das imunidades tributárias, que não vêm para beneficiar particulares.

Não obstante, há um equívoco nesse raciocínio, pois, na hipótese do parágrafo 1º, há identidade tanto entre o valor de declaração dos imóveis e o valor de face das ações ou quotas emitidas, quanto, no parágrafo 2º, entre o valor de mercado dos imóveis e o valor de mercado das ações ou quotas com eles integralizadas.

Atento a essa circunstância, Igor Maüler Santiago leciona:

Assim sendo, fica claro que a controvérsia decorre de um elemento alheio à tributação municipal. Os municípios se utilizam de um benefício concedido pela União e pretendem dele extrair algum ganho para si, sem que nada em sua esfera jurídica tenha sido afetado. De fato, se a integralização ocorresse pelo valor de mercado, tudo o que se teria seria a incidência imediata do imposto de renda sobre o ganho de capital, sem o nascimento de qualquer dever de ITBI. Por que razão a integralização por um valor menor (e contra ações ou quotas com um valor de face também menor) deveria atrair a incidência do imposto municipal? ¹⁰

Em contexto inverso, mas aplicável e paradigmático, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp no1.517.492/PR11, analisou a impossibilidade de tributação por um ente político sobre benefício fiscal concedido por outro, afastando, na hipótese, a incidência de IRPJ e CSLL sobre créditos presumidos de ICMS (subvenções para investimento).

Na ocasião, o Superior Tribunal de Justiça deixou claro que a pretensão fiscal ali analisada equivaleria à "possibilidade de a União retirar, por via oblíqua, o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou", aniquilando "instrumento legítimo de política fiscal para materialização da autonomia consagrada no modelo federativo". Assinalou-se que "a tributação pela União de valores

¹⁰ ¹⁰ SANTIAGO, Igor Maüler. "Imunidade do ITBI independe da forma de avaliação do imóvel colacionado. Consultor Tributário". Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mar-06/consultor-tributario-imunidade-itbi-independe-avaliacao-imovel-colacionado> Acesso em: 28/06/2021

¹¹ 1ª Seção, relatora para o acórdão ministra Regina Helena Costa, DJe 1/2/2018

Rua Judith Maria Tovar Varejão, 373, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abreujudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477



correspondentes a inventivo fiscal estimula competição indireta com o Estado-membro, em desprezo à cooperação e à igualdade, pedras de toque da Federação". O inevitável "abalo na credibilidade e na crença no programa estatal proposto pelo Estado-membro" causaria "desdobramentos deletérios no campo da segurança jurídica". E finaliza: "o ressurgimento do encargo, ainda que sob outro figurino" torna "inócua, ou quase, a finalidade colimada pelos preceitos legais".

Nesse sentido, de certo modo, são as palavras do tributarista Igor Maüler Santiago em artigo publicado na **ConJur**:

"Ora, se a União não pode passar por cima de lei estadual para tributar benefício concedido por Estado-membro, por que motivo poderia o município apear imunidade constitucional para tributar isenção — na verdade, um simples diferimento, pois o ganho de capital será tributado na futura alienação das ações ou quotas integralizadas com imóveis — outorgada por lei federal?"¹²

E vai adiante o ilustre tributarista citado, ao analisar o disposto no art. 38 do CTN:

E nem se alegue que a exigência aqui discutida teria assento no artigo 38 do CTN, segundo o qual "a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos". **Não se decide sobre a configuração da hipótese de incidência com recurso a elementos do consequente normativo, que só se instaura uma vez verificada aquela. A petição de princípio é insuperável.**

Tampouco cabe invocar o princípio de que as imunidades só devem ser reconhecidas se atendidas as suas finalidades, para que não se transformem em privilégios odiosos. **A imunidade em debate visa fomentar o surgimento de novas empresas e o crescimento daquelas já existentes, o que sem dúvida decorre da leitura aqui predicada — e é obstado pela visão restritiva posta sob censura.**

Como visto, o ato coator, ao pegar de empréstimo os fundamentos do respeitável Parecer da ilustre Procuradoria do Município de Guarapari absorveu toda a ilegalidade e a inconstitucionalidade decorrentes de manifesto equívoco jurídico na

¹² SANTIAGO, Igor Maüler. "Imunidade do ITBI independe da forma de avaliação do imóvel colacionado. Consultor Tributário". Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-mar-06/consultor-tributario-imunidade-itbi-independe-avaliacao-imovel-colacionado> Acesso em: 28/06/2021.



interpretação do quanto dispõem o art. 156, §2º, I, da CF, arts. 36, I e II e 38, do CTN, esquecendo-se, por sua vez, do quanto disciplina o art. 23 e parágrafos da Lei nº 9.249/1995.

Muito importante enfatizar que o ato coator, ao acolher o parecer da Procuradoria Municipal, absorveu os seus equívocos interpretativos, sua incongruência e sua assimetria ao pretender reescrever, *data venia*, a regra constitucional, de redação clara e límpida.

Não obstante o ato coator tenha reconhecido a imunidade tributária até o limite do valor atribuído ao bem por ocasião da integralização na formação do capital da sociedade empresária, pretendeu ir além do texto constitucional para exigir o ITBI sobre uma diferença de valor que não pode ser imputada à impetrante para a conclusão da operação de integralização e transferência dominial perante o competente Cartório de Registro de Imóveis.

Eis a dicção do Parecer da Procuradoria Municipal que fundamentou o ato coator:

11. Ao lado do que acima foi dito, importa destacar que a imunidade em exame adstringe-se ao valor necessário à integralização do capital social, pois o artigo 36 do Código Tributário Nacional faz menção de que a não-incidência (*rectius*, imunidade) limita-se ao capital subscrito (*in casu*, incorporado), não sendo razoável sua concessão quanto ao valor total do imóvel incorporado, se excedente.

12. Diante desse cenário, à luz do estatuído no art. 36 do CTN, caso o valor de mercado do imóvel que, por força da incorporação, passará ao patrimônio da Requerente supere o valor a ele atribuído para fins de integralização, o ITBI incidirá sobre a parte excedente.

13. Quanto ao ponto, forçoso destacar a tese fixada pelo Excelso Pretório no tema 796, *litteris*: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”⁸.

Acima a impetrante destacou uma importante circunstância que não foi observado pelo ato coator:

o imóvel em epígrafe (Apartamento nº 201, do Edifício Praia de Bacutia, situado na avenida Viña del Mar, na Enseada Azul, Nova Guarapari, neste município) foi integralizado ao capital social da impetrante pelo exato

Rua Judith Maria Tovar Varejão, 373, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abreujudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477



valor declarado pelos sócios à Receita Federal em sua Declaração de Bens, e transformado em cotas subscritas (220 mil cotas), não havendo qualquer diferença a maior, ou a menor. Não houve, portanto, discrepância entre o patrimônio da sociedade e o seu capital, no pormenor, tampouco, parte a conta de reserva de ágio ou capital

No caso sob apreciação apresenta-se abusiva e ilegal a exigência de ITBI sobre a diferença entre o valor de aquisição ou de integralização, na formação do capital societário da Impetrante, e o valor venal do imóvel ¹³ em virtude de atualização compulsória pelo Município de Guarapari ao valor de mercado.

Dessa feita, resta clarividente que a Impetrante faz jus ao reconhecimento do seu direito líquido e certo de não sofrer a incidência do ITBI pelo fato de haver integralizado o imóvel apartamento nº 201, do Edifício Praia de Bacutia, situado na avenida Viña del Mar, na Enseada Azul, em Nova Guarapari, pelo valor constante da declaração de bens do seu sócio, como parte do capital social, sem que qualquer valor tenha sido reservado à conta de ágio, não sendo, pois, legítima qualquer exigência do imposto municipal sobre a diferença entre o valor integralizado e o valor venal ou de mercado atribuído pelo Autoridade Impetrada¹⁴, conforme certidão em anexo (Doc. 10).

Mas não é só, o ato coator, além de pretender tributar a diferença entre o valor pelo qual foi integralizado o imóvel, tal qual constava da declaração de bens do seu respectivo sócio, e o valor venal por ela atribuído, **vai além, contrariando, ainda mais, o precedente do Supremo Tribunal Federal, pois, ao acolher integralmente o Parecer do Douto Procurador Municipal, pretende, também, impor à impetrante as limitações previstas no art. 37, do CTN, quando o mesmo não fora recepcionado pelo inciso I, do § 2º do art. 156, do Constituição Federal.**

O voto vencedor do ministro Alexandre de Moraes, prosseguindo na distinção das imunidades para "realização de capital" (integralizações) e "incorporação de bens" (fusão, cisão ou incorporação), **concluiu, com todas as letras, que a primeira**

¹³ Apartamento nº 201, do Edifício Praia de Bacutia, situado na avenida Viña del Mar, na Enseada Azul, Nova Guarapari, neste município

¹⁴ A propósito, o Município de Teixeira de Freitas (BA) reconheceu a não-incidência do ITBI sobre integralização do imóvel rural pertencente ao sócio Fernando de Abreu Júdice na realização do capital social da Impetrante, isso em razão de uma adequada e perfeita interpretação das regras constitucionais e legais, bem como do precedente do STF, correspondente ao RE nº 796.376/SC, Tema 796.



hipótese de imunidade é incondicionada, enquanto na segunda a imunidade só é aplicável caso a sociedade incorporadora do patrimônio imobiliário não desenvolva atividade preponderantemente imobiliária, asseverando a não-recepção do disposto no art. 37, do CTN, para a hipótese prevista no inciso I, do art. 36.

Vejamos os fundamentos do Ato Coator, em descompasso com o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal:

5. A demarcação dos limites da regra imunizante em análise é encontrada nos artigos 36 e 37 do CTN, que assim dispõem:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I – Quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento do capital nela subscrito;

II – quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.

Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a quem foram conferidos.

Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.

§ 1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.

§ 2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.

§ 3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data.

6. Como se vê, a hipótese de incidência da regra imunizante em exame toma como referência a **receita operacional** da pessoa jurídica adquirente, de sorte que, na análise de sua aplicação, o que prepondera não é o objeto social indicado no ato de constituição da interessada, e sim a substância da atividade econômica por ela desempenhada nos dois anos anteriores e nos dois anos



subsequentes a aquisição, ou nos três anos seguintes a aquisição, caso caracterizada a hipótese do §3º do art. 36 do CTN.

7. Tratando-se de pessoa jurídica constituída há menos de 2 (dois) anos⁴, a exoneração do tributo ficará condicionada durante o triênio seguinte à aquisição, convalidando-se, a depender da atividade preponderante, depois dele: em suma, o imposto ficará diferido até que se complete o termo⁵.

8. No caso vertente, não havendo como se aferir, agora, se a Requerente faz ou não jus à imunidade de que trata o inciso I do §2 do art. 156 da CRFB, deve-se autorizar a integralização do imóvel em seu capital independentemente do pagamento do ITBI, porém sem prejuízo da futura cobrança de tal imposto, caso se constate, ao fim do termo aludido no 2º do art. 37 do CTN, que sua receita operacional preponderantemente advém das atividades listadas no *caput* de retrocitado dispositivo.

9. Encerrado o triênio versado no §2º do art. 37 do CTN, cumprirá a esta Municipalidade⁶, por meio de sua Secretaria de Fazenda, verificar qual atividade preponderante da Requerente, isto é, de onde provém a maioria de suas receitas operacionais, sendo certo que, no desempenho de tal tarefa, devem ser consideradas não só suas receitas próprias, senão também as provenientes de sociedades nas quais tenha participação⁷.

A Impetrante cuida-se de *holding* familiar onde as atividades preponderantes estão relacionadas às atividades agropecuárias da filial localizada em Teixeira de Freitas na Bahia (Doc. 5): Matriz: CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL - 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras. Por sua vez, os balancetes da empresa que instruíram o pedido de imunidade tributária demonstram que a receita operacional não está poluída com recebíveis decorrentes de atividade imobiliária (compra, venda locação, etc.) No caso da Abreu Judice Participações Ltda a receita advém em sua totalidade da atividade agropecuária.

Não obstante o que acima se afirma e comprova, embora a Impetrante, Abreu Júde Participações Ltda¹⁵, não atue no ramo imobiliário de venda de bens

¹⁵ Matriz:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS;

01.51-2-01 - Criação de bovinos para corte

01.51-2-02 - Criação de bovinos para leite

01.51-2-03 - Criação de bovinos, exceto para corte e leite

01.52-1-01 - Criação de bufalinos

01.52-1-02 - Criação de equinos

01.52-1-03 - Criação de asininos e muas

Rua Judith Maria Tovar Varejão, 373, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abrejudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477



e direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil, **essa indevida limitação pretendida pela municipalidade restringe legítimo direito seu de, eventualmente, antes do triênio previsto no inciso II, do art. 37, do CTN, alterar seu objeto social, direcionando-o para as atividades imobiliárias**

Essa interpretação conferida ao disposto tanto na Constituição Federal quanto no CTN, discrepa da *ratio decidendi* constante do acórdão do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE nº 796.376/SC, Tema 796, oportunidade na qual restou assentado, com todas as letras, que a limitação constante do art. 37, do CTN, não se aplica à hipótese regulada no inciso I, do art. 36, exatamente àquela prevista na primeira locução constante do inciso I, do § 2º do art. 156, da Constituição Federal.

Eis o quanto decidido pelo STF, ressaltando que não o fora em *obiter dictum*, mas sim como argumentação sistêmica de compatibilidade da legislação infraconstitucional com a Carta Magna, em verdadeira *ratio decidendi*. Vejamos o voto vencedor do ministro Alexandre de Moraes, no pormenor:

Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I - "nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil" - revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma

01.53-9-01 - Criação de caprinos
01.53-9-02 - Criação de ovinos, inclusive para produção de lã
01.59-8-99 - Criação de outros animais não especificados anteriormente
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
01.62-8-99 - Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
Filial:
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
01.51-2-01 - Criação de bovinos para corte
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.51-2-02 - Criação de bovinos para leite
01.51-2-03 - Criação de bovinos, exceto para corte e leite
01.52-1-01 - Criação de bufalinos
01.52-1-02 - Criação de equinos
01.52-1-03 - Criação de asininos e muarens
01.53-9-01 - Criação de caprinos
01.53-9-02 - Criação de ovinos, inclusive para produção de lã
01.59-8-99 - Criação de outros animais não especificados anteriormente
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
01.62-8-99 - Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente

Rua Judith Maria Tovar Varejão, 373, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abrejudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477



preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão “nesses casos” não alcança o “outro caso” referido na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF.

Ou seja, a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso.

Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital. Reitere-se, as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. **Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito.**

(...)

Disso decorre, logicamente, que, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o valor do capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI, **pois a imunidade está voltada ao valor destinado à integralização do capital social, que é feita quando os sócios quitam as quotas subscritas.** [no destaque, exatamente a hipótese da Impetrante]

Por outro lado, nada impede que os sócios ou os acionistas contribuam com quantia superior ao montante por eles subscrito e que o contrato social preveja que essa parcela será classificada como reserva de capital. Essa convenção se insere na autonomia de vontade dos subscritores.

O que não se admite é que, a pretexto de criar-se uma reserva de capital, pretenda-se imunizar o valor dos imóveis excedente às quotas subscritas, ao arrepio da norma constitucional e em prejuízo ao Fisco municipal.

Ainda que o preceito constitucional em apreço tenha por finalidade incentivar a livre iniciativa, estimular o empreendedorismo, promover a capitalização e o desenvolvimento das empresas, não chega ao ponto de imunizar imóvel cuja destinação escape da finalidade da norma. No caso concreto, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R\$ 778.724,00. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa, cujo capital social é de R\$ 24.000,00, pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital, e, sobretudo, livre do pagamento de imposto.

Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado.

Por todos os argumentos dispendidos chega-se às seguintes conclusões:

Rua Judith Maria Tovar Varejão, 373, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abrejudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477



a) não incide ITBI sobre a integralização do imóvel, do apartamento nº 201, do Edifício Praia de Bacutia, situado na avenida Viña del Mar, na Enseada Azul, em Nova Guarapari, neste município, como parte de capital da impetrante, que foi adquirido e constava da Declaração de Imposto de Renda dos seus então proprietários, casados em comunhão universal de bens, Fernando de Abreu Júdice e Ana Rita Marques Júdice, pelo valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), convertendo-se em 220 mil cotas;

b) não houve por ocasião da integralização do referido imóvel qualquer registro de parte do valor do imóvel à conta de reserva de capital ou de ágio, não se aplicando a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 796, em regime de repercussão geral, pelo STF;

c) não se aplicam ao caso *sub judice* as limitações previstas nos §§ 1º a 3º do art. 37, do CTN, ou seja, essas limitações são incompatíveis à hipótese prevista no inciso I, art. 36, do mesmo Diploma.

d) O art. 37, do CTN, foi recepcionado, parcialmente, pelo disposto no inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF, não sendo aplicável quando se tratar de **"transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital"**, em razão do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 796.376/SC, Tema 796.

Tollitur quaestio!

Inexorável, pois, o direito líquido e certo da Impetrante em não se submeter à incidência do ITBI sobre o ato de integralização do imóvel descrito no capital social da Impetrante.

VII. DA LIMINAR E DO PERICULUM IN MORA – NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR O DIREITO EVIDENTE

O Ato Coator está a submeter a Impetrante a uma inconstitucional e ilegítima exação a título de ITBI, conforme já evidenciado acima, o que se comprova pela guia para recolhimento do tributo (Doc. 05) expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, cujo valor, em 28 de maio de 2021, alcançava a importância de R\$ 17.690,11 (dezesete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos).

Dessa feita, a Impetrante vê-se impedida de transferir para si a propriedade imobiliária integralizada em seu capital - o apartamento nº 201, do Edifício Praia de Bacutia, situado na avenida Viña del Mar, na Enseada Azul, em Nova Guarapari, neste município - pelo valor constate da declaração de bens de direitos do sócio Fernando de Abreu Júdice, sem que se submeta à exigência de qualquer valor a título de ITBI, nos exatos termos

Rua Judith Maria Tovar Varejão, 373, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abrejudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477



do que lhe garante a primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF c/c o inciso I, do art. 36, do CTN.

A propósito, o parágrafo 2º da Cláusula primeira do Instrumento de Alteração Contratual nº 1 e Consolidação da Sociedade Limitada, registrado perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, em 20.05.2020, estabelece o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias para que a Impetrante efetive a transferência dos imóveis que integralizaram o seu capital, a saber:

Parágrafo Quarto: A transferência efetiva da propriedade dos referidos bens imóveis, em favor da sociedade, será processada no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da data de efetivação do registro destes atos constitutivos perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, devendo em igual prazo, serem arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, certidões imobiliárias, comprovando a transferência dos imóveis, restando assim concretizada a integralização do capital social da sociedade, ficando, no entanto, desde já, investida a Sociedade na posse direta sobre os bens, fazendo uso livre dos mesmos e deste tirando proveito.

Portanto, ultrapassado o prazo constante do contrato social para que tais transferências se efetivem, a Impetrante ficará devedora de seus sócios e, ainda, vulnerável econômica e financeiramente em suas atividades, na medida em que não poderá fruir dos imóveis para efeito de garantias bancárias em operações de crédito, comprometendo, em demasia, a sua liberdade econômica, seus projetos comerciais e mercantis etc.

Por sua vez, cada um dos sócios, uma vez afetados os imóveis à integralização, também não poderão se valer dos mesmos para efeitos comerciais outros e, tampouco, para obtenção de créditos bancários. Não obstante, os imóveis ainda não transferidos no Registro de Imóveis para o nome da Impetrante ficam juridicamente a mercê de responder pelas dívidas dos sócios, nos termos do quanto preveem o art. 391, CCB/2002¹⁶ e art. 789, CPC/2015¹⁷.

Essa surreal situação não pode ser perenizar no tempo diante de uma ilegal exigência do ITBI, estabelecendo-se um verdadeiro engessamento da atividade empresarial, econômica e financeira da Impetrante.

¹⁶ Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor.

¹⁷ Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.



Não é demais lembrar o julgamento, pelo STJ, do REsp nº 1.743.088/PR, a 3ª Turma, onde se decidiu que a simples inscrição do ato constitutivo da sociedade na Junta Comercial não é suficiente para efetivar a transferência da propriedade imobiliária à sociedade empresária, sendo absolutamente necessário o registro perante a matrícula no Cartório de Registro Geral de Imóveis.

É o que disciplina o art. 64 da Lei de Registro Público de Empresas Mercantis (Lei n. 8.934/94, ao dispor que *"[a] estipulação prevista no contrato social de integralização do capital social por meio de imóvel devidamente individualizado, indicado pelo sócio, por si, não opera a transferência de propriedade do bem à sociedade empresarial"*.

Portanto, o contrato social, ainda que devidamente registrado na Junta Comercial, apenas constitui título translativo hábil à transferência da propriedade imobiliária, que somente se aperfeiçoa como determina o art. 1.245, do CCB/2002¹⁸.

Desse modo, quanto maior for o tempo de espera para a transferência do domínio perante o Cartório de Registro de Imóveis, mais vulnerável fica a Impetrante e seus sócios, estes em razão de que, por eventuais débitos seus, os imóveis integralizados, mas cujo domínio ainda não fora trasladado, continuam como parte integrante do seu patrimônio, podendo vir a ser constritos por dívidas suas, diante da dinâmica dos fatos da vida.

Para além, deve-se alertar a Vossa Excelência, que a não-integralização do capital social, na sociedade limitada^[5], implica responsabilização solidária de todos os sócios pelas obrigações contraídas pela sociedade empresária, até o limite do valor não integralizado, correspondente ao valor dos imóveis na hipótese em questão.

Nesse diapasão, de duas, uma: i) ou a Impetrante se sujeita à ilegal e à inconstitucional exação tributária para efeito de obter a competente certidão municipal para propiciar o traslado do domínio do imóvel perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis competente; ii) ou, obtém a concessão de ordem mandamental, liminarmente e por sentença,

¹⁸ Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.



para efeito de, uma vez reconhecido o seu direito líquido e certo à imunidade (não-incidência) do imposto municipal, em razão da integralização do imóvel no capital social da sociedade empresária, lograr transferir a propriedade imobiliária sem o indevido custo tributário, garantindo a sua normal sobrevivência e suas operações comerciais.

O tempo urge! E, a cada dia sem que o patrimônio integralizado não esteja devidamente transferido para o domínio da Impetrante a vulnerabilidade da sociedade empresária e de seus sócios se agiganta.

Demonstrado, pois, o *periculum in mora*, a justificar a urgência para a concessão da tutela liminar a ser requerida, com espeque no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, sob pena de, ao final, restar ineficaz quanto ao bem imóvel pretendido diante da vulnerabilidade patrimonial, à luz do disposto nos arts. 391, CCB/2002 e art. 789, CPC/2015. Essa possibilidade não é apenas virtual, mas sim real diante do que preveem a lei civil e a lei processual mencionadas.

Faz jus a Impetrante à concessão da ordem, tanto liminar quanto por sentença, nos termos dos pedidos abaixo lançados.

VIII. DOS PEDIDOS – LIMINAR E DE MÉRITO

Considerando toda a fundamentação acima exposta, em especial o resultado do julgamento do RE nº 796.376/SC, Tema 796, pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, bem como a materialidade e a inconstitucionalidade do Ato Coator, devidamente comprovadas por prova documental idônea, a Impetrante passa a lançar os seus pedidos de liminar e de mérito, a saber:

VIII.1 – Dos pedidos de liminar:

a) evidenciado o *periculum in mora* e o direito líquido e certo deduzido, requer a Impetrante seja deferida, com fulcro no inciso III, do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, **medida liminar para efeito de ordenar à Autoridade Impetrada e os demais prepostos da Secretaria de Fazenda do Município de Guarapari que se abstenham de exigir o ITBI na importância de R\$ 17.690,11** (dezessete mil, seiscentos

Rua Judith Maria Tovar Varejão, 373, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abrejudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477



e noventa reais e onze centavos), apurada em 28.05.2021, ou qualquer outra, sobre a diferença entre o valor do imóvel acima destacado, constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice (R\$ 220.000,00 – duzentos e vinte mil reais), e como tal integralizado como capital da sociedade empresaria em 220 – duzentos e vinte – mil cotas, e o valor de avaliação levado a efeito pela municipalidade (R\$ 880.000,00 – oitocentos e oitenta mil reais), em razão da imunidade tributária (não-incidência) prevista na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF c/c o inciso I, do art. 36, do CTN;

b) igualmente, considerando que não se aplicam ao caso *sub judice* as limitações previstas nos §§ 1º a 3º do art. 37, do CTN, uma vez incompatíveis com a hipótese prevista no inciso I, art. 36, do mesmo Diploma, requer **seja deferido liminarmente ordem dirigida à Autoridade Impetrada e aos demais prepostos da Secretaria de Fazenda do Município de Guarapari para que se abstenham de exigir da Impetrante a observância do quanto previsto nos §§ 1º a 3º do art. 37, do CTN**, em razão de sua não-aplicação à hipótese prevista na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF (**“transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital”**), c/c o inciso I, do art. 36, do CTN, devido a sua não-recepção pela Carta Manga de 1988.

VIII.2 – Dos pedidos de mérito:

a) por sentença de mérito, seja reconhecido o direito líquido e certo de a impetrante fazer jus à imunidade tributária do ITBI sobre transmissão do apartamento no 201, do Edifício Praia de Bacutia, situado na avenida Viña del Mar, na Enseada Azul, em Nova Guarapari, neste município, incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, sem qualquer reserva de valor à conta de capital ou de ágio, prevalecendo o valor constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice (R\$ 220.000,00 – duzentos e vinte mil reais), e como tal integralizado como capital da sociedade empresaria em 220 – duzentos e vinte – mil cotas, afastando, definitivamente e por completo, a exação de R\$ 17.690,11 (dezessete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos), em 28.05.2021, ou qualquer outra a ser apurada, ilegalmente, sobre a diferença entre o valor do imóvel acima destacado, constante da declaração de bens do sócio Fernando de Abreu Júdice e o valor de avaliação levado a efeito pela municipalidade (R\$ 880.000,00 – oitocentos e oitenta mil reais);

Rua Judith Maria Tovar Varejão, 373, Enseada do Suá, Vitória - ES | cep 29050-360
e-mail: advocacia@abreujudice.com.br | tel/fax (27) 3223-5477



b) também, no mérito, seja definitivamente reconhecido que a imunidade a que faz jus a Impetrante não encontra limitações previstas nos §§ 1o a 3o do art. 37, do CTN, uma vez incompatíveis com a hipótese prevista no inciso I, art. 36, do mesmo Diploma, em razão de sua não-aplicação à hipótese prevista na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF (**"transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital"**).

Seja, nos termos do art. 7º, I, da Lei 12.016/2009, notificada à Autoridade Impetrada que preste as informações de estilo que julgar necessárias, exibindo o inteiro teor do procedimento administrativo nº 18.384/2020, tal qual previsto no §§ 1º e 2º do art. 6º da citada lei.

Dá-se à causa o valor de R\$ 17.690,11 (dezesete mil, seiscentos e noventa reais e onze centavos).

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

De Vitória/ES para Guarapari/ES, 21 de julho de 2021

RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE
OAB-ES 7.513

LUCIANA MARQUES DE ABREU JÚDICE
OAB-ES 5.868

RENAN DE ANGELI PRATA
OAB-ES 16.017

ENZO SCARAMUSSA COLOMBI GUIDI
OAB-ES 34.648



Documentos anexos:

- Doc. 01 – Procuração
- Doc. 02 – Atos constitutivos da Matriz e da Filial
- Doc. 03 – CNPJ Matriz e Filial
- Doc. 04 – Cópia Integral do Procedimento Administrativo no âmbito da SEFAZ -
Ato Coator
- Doc. 05 – Guia de Recolhimento do ITBI expedida pela Secretaria de Fazenda do
Município de Guarapari
- Doc. 06 – Corrente de e-mails
- Doc. 07 - Declaração de bens de Fernando de Abreu Júdice
- Doc. 08 – IRPF – 2021/2021- Declaração
- Doc. 09 – IRPF – 2021/2021 – Recibo de Entrega
- Doc. 10 - Certidão Município Teixeira de Freitas

